

第13問

散歩中の甲は、乙が自宅前に鎖でつないでおいた乙の猛犬を見て、いたずら半分に石を投げつけたところ、怒った猛犬が鎖を切って襲いかかってきたので、やむなく隣家丙の居間へ逃げ込んだ。情を知らない丙は、突然、土足で室内へ飛び込んできた甲を見て憤慨し、甲の襟首をつかんで室外へ突き出したところ、甲は猛犬にかまれて重傷を負った。

甲、乙及び丙の罪責を論ぜよ。

(旧司法試験 昭和58年度 第1問)

第1 甲の罪責

丙宅へ立ち入った行為について、住居侵入罪（130前段）の構成要件に該当することを確認した後、緊急避難（37 I 本文）の成否を検討することになる。

乙の猛犬が襲いかかってきたのは、甲がいたずら半分で石を投げつけたことに起因するものであるから、自招危難の問題を論じる必要がある。

いたずら半分で石を投げつけたことの過失の程度、猛犬が鎖を切って襲いかかってきたことへの予見可能性等を指摘して結論を導く必要がある。

第2 丙の罪責

甲を室外へ突き出した行為について、暴行罪（208）を成立させた後、傷害罪（204）の成否を検討する（**論点** 傷害の故意）。傷害罪を暴行罪の結果的加重犯と捉える判例の立場（最判昭22.12.15）からは、因果関係が認められる本件では、傷害罪の構成要件を充足すると考えてよいだろう。

次に、違法性阻却事由の有無であるが、ここで甲に緊急避難を成立させている場合には、緊急避難の法的性格を論じる必要がある（**論点** 緊急避難の法的性質）。

緊急避難を違法性阻却事由であると捉える通説の立場に立てば、これに対する正当防衛は成立しないから、緊急避難の成否を検討することになるが、責任阻却事由説に立てば正当防衛（36 I）の成否を検討することになる。

緊急避難を検討した場合には、まず、甲に対して憤慨していることから、避難の意思の有無が問題となるが、防衛の意思における判例理論（最判昭46.11.16、最判昭50.11.28【百選 I 24】、最判昭60.9.12）とパラレルに考えれば避難の意思は認められうる。

もっとも、本問では、他にとり得る手段がないとはいえないから、補充性を満たさないだろう（かつ、法益の権衡も満たさない。）。

補充性を満たさない場合に、過剰避難（37 I ただし書）の成立を認めるか否かについては争いがあり、肯定する立場（東京高判昭57.11.29）からは過剰避難として処理することになろう。

なお、丙は事情を知らなかったのだから、主観的には甲の行為が「不正の侵害」に当たり、正当防衛が成立する可能性がある（誤想防衛）。もっとも、被侵害法益（丙の住居権）と失われた法益（甲の身体の安全）の権衡、襟首をつかんで室外へ突き出すという行為の態様から考えれば、「やむを得ずにした行為」には当たらないだろう（誤想過剰防衛）（**論点** 誤想（過剰）防衛  司判H29,R4,予R2,旧H6-1,H9-1）。

 総合 170 頁  論証 70 頁

 総合 77 頁  論証 24 頁

 総合 91 頁  論証 35 頁

第3 乙の罪責

過失傷害罪（209 I）の成否を論じる。問題文の具体的事情が明らかではないものの、犬が切ることができるような鎖で猛犬を管理していた以上、過失があると見ることができるだろう。因果関係も認められるだろう。

答案構成

第1 甲の罪責

1 住居侵入罪（130前段）



2 緊急避難（37 I 本文）の成否



要件検討



自招危難



行為者において何らかの避難行為に出ることが社会的に正当とされる状況にあるか否か



あてはめ



3 甲には住居侵入罪は成立しない

第2 丙の罪責

1 傷害罪の成否（204）



2 故意（38 I）の成否



傷害罪は暴行罪（208）の結果的加重犯



暴行の故意があれば足りる



あてはめ



3 正当防衛（36 I）又は緊急避難の成否



緊急避難の法的性格



違法性阻却事由説



緊急避難の成否



要件検討



4 過剰避難成立（37 I ただし書）

第3 乙の罪責

過失傷害罪（209 I）成立

第1 甲の罪責

1 甲が丙の居間へ逃げ込んだ行為は、「正当な理由がないのに、人の住居……に侵入し」たものとして、住居侵入罪（130条前段）の構成要件に該当する。

2(1) もっとも、この行為は乙の猛犬が鎖を切って襲いかかってきたのに対して、これを避けるために行われたものであり、緊急避難（37条1項本文）の成立可能性がある。

猛犬が襲いかかってきたことは「自己……身体……に対する現在の危険」に該当する。また、甲は、これを避けるためやむなく丙の居間へ逃げ込んでいるから、上記危険を「避けるため、やむを得ずにした行為」（避難の意思、補充性）に当たる。さらに、生じた害は丙の住居権侵害である一方、避けようとした害は甲の生命又は身体に対する侵害であるから、「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった」こと（法益の権衡）も認められる。

(2) もっとも、乙の猛犬が襲いかかったのは甲がいたずら半分に石を投げつけたことに起因するものであり、いわゆる自招危険に当たる。このことを理由として、緊急避難の成立が否定される場合があり得る。

自招危険の事例においては、状況を総合しての評価的な認定にならざるを得ない場合も多く、特定の要件の問題とするにそぐわない。

そこで、挑発行為における過失の程度、危険の予期の有無、予期の可能性の有無とその程度、予期し又は予測可能であった危険の内容と実際の危険の異同等の具体的事情を考慮に入れ、行為者において何ら

1

かの避難行為に出ることが社会的に正当とされる状況にあるか否かで緊急避難の成否を決すべきである。

(3) 確かに、いたずら半分に石を投げつけた甲の過失の程度は大きいし、猛犬に対して石を投げつけた場合、猛犬が襲いかかってくるといふことについては予見できるものとも思われる。

しかし、本件では乙の猛犬は鎖でつながれており、一般に鎖が容易に切断できるものではない以上、猛犬が鎖を切ってまで襲いかかってくるといふことを予期することは困難である。

したがって、本件では緊急避難の成立を肯定できる。

3 以上より、甲には住居侵入罪は成立しない。

第2 丙の罪責

1 丙が甲の襟首をつかんで室外へ突き出したところ、甲は猛犬にかまれて重傷を負っているから、「人の身体を傷害した」ものとして、傷害罪（204条）の成立が考えられる。

2 本件では、丙が甲の傷害結果についての認識（故意、38条1項）を有しない可能性がある。

しかし、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という208条の文言からすれば、「暴行を加えた者」が「人を傷害するに至」った場合の規定として、傷害罪は暴行罪（208条）の結果的加重犯をも包含すると解すべきである。そのため、行為者が暴行の認識を有しており、暴行と傷害結果との間の因果関係が認められれば傷害罪は成立し得るため、この点は同罪成立の障害とはならない。

2

本件では上記丙の行為によって室外に突き出された甲が猛犬にかまれて重傷を負っているのだから、行為の危険が現実化したといえ、丙の上記行為（暴行）と甲の傷害結果との間の因果関係が認められる。

したがって、構成要件該当性は肯定できる。

3(1) もっとも、上記丙の行為は甲が丙の居間に逃げ込んだことに対して行われたものであり、正当防衛（36条1項）又は緊急避難が成立し得る。ここで、甲の行為は緊急避難に該当するものであるから、緊急避難の法的性格を検討する必要がある。

(2) この点について、責任阻却事由にすぎないとする見解がある。この見解からは、緊急避難行為に対して正当防衛をなし得ることになる。

しかし、37条1項本文は、他人の行為についての緊急避難を認めているが、このような場合には、期待可能性がないとはいえない。

反対に、避難によって侵害される利益が保全される法益よりも大きくても責任が失われる場合はあるはずである。しかし、緊急避難の成立要件として、法益権衡の原則が採用されている。そうだとすれば、緊急避難の成否は違法性のレベルで判断するのが妥当である。

そこで、緊急避難は重要な利益を保全するための社会的に相当な行為であるとして、違法性阻却事由の一つと考えるべきである。

(3) そうすると、適法行為は「不正の侵害」に該当しないから、正当防衛は成立せず、緊急避難の要件を検討することになる。

甲は、丙の住居にすでに立ち入っているから、「現在の危険」は認められる。また、丙は甲に憤慨して上記行為に及んでいるものの、避

3

難行為時の意思内容としては、現在の危険の認識と危険に対応する意思があれば足り、避難の意思と攻撃の意思とが併存している場合の行為は、必ずしも避難の意思を欠くものではないと解すべきであるから、丙に甲の侵害行為に対して住居権を守るとい意思がある限り、避難の意思は否定されない。

もっとも、本件では警察に通報するなどの他の手段が考えられるから、補充性は認められない。

(4) よって、緊急避難の成立は認められず、傷害罪が成立する。

補充性が認められない場合には、条文上過剰避難（37条1項ただし書）は成立しない。もっとも、補充性が欠けても保全法益が維持されたということは変わらない以上、違法性はこの場合も減少するといえ、過剰避難の成立を肯定してよいと解する。

4 以上より、丙には傷害罪が成立し、過剰避難となる。

第3 乙の罪責

乙については、「過失により人を傷害した」ものとして、過失傷害罪（209条1項）が成立する。すなわち、本件では、具体的事情は明らかではないものの、乙は、犬が切ることができるような鎖で力の強い猛犬を管理していたのだから、過失は認められるといえるだろう。そして、甲に傷害結果が生じる過程では、上記甲及び丙の行為が介在しているものの、猛犬の管理に関する上記乙の過失行為の結果への寄与度が極めて高いと考えられるから、乙の過失行為の危険が結果として現実化したものとして、因果関係も認められる。

以上

4